

1501250-26.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado negou o delito.

Todavia, os policiais o viram em local de tráfico, com 38 porções de drogas, e dinheiro (R\$ 40,00) cuja procedência não foi delineada.

Aliás, na fase policial, o acusado assim se manifestou (fls. 08): "(...) Disse que está passando por dificuldades e que recentemente até pensou em praticar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501250-26.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501250-26.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2308586/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21352347 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 8360/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2308586 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 8360/21/050 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON EDUARDO DOS SANTOS CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Marlon Eduardo dos Santos Carvalho, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 11 de novembro de 2021, por volta de 10h, na Avenida Pedro de Toledo, quadra 01, bairro Vila Guaggio, na cidade e comarca de Bauru-SP, trazia consigo 7,05 gramas de crack, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 15/19) e laudo definitivo (fls. 176/179).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 39/43), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 66/68, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 76), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 79).

Na decisão de fls. 86/87, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 126/128, foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o acusado.

Pela decisão de fls. 135/137, foi concedida a liberdade provisória ao acusado, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Durante a audiência em continuação de fls. 155/156, ocorreu o pedido de desistência da oitiva da testemunha de defesa. Na mesma ocasião, foi o acusado novamente interrogado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 164/170 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, exasperando-se a pena nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da agravante do 'estado pandêmico', e do "tráfico privilegiado", fixando-se o regime semiaberto.

Já a D. Defesa Constituída às fls. 174/175 pleiteou, em síntese, pela absolvição do acusado, por ausência de provas, ou a desclassificação para o delito de consumo, com o afastamento da agravante do "estado pandêmico", a valoração do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a fixação regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritivas de direitos, possibilitando-se eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 15/19) e laudo definitivo (fls. 176/179).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Cláudio de Oliveira Júnior e Genivaldo de Souza, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que estavam em patrulhamento pela Avenida Pedro de Toledo, quando avistaram o acusado sentado num ponto de ônibus. Afirmaram que assim que ele viu a viatura, demonstrou nervosismo, se levantou e entrou num terreno baldio. Informaram que, com a abordagem, havia, com ele, 38 pedras de 'crack', e, em seu bolso, 40 reais em dinheiro. Esclareceram que ele confessou a traficância. Mencionaram que o local é frequentado por usuário e traficantes, sendo próximo da linha férrea. Citaram que, aparentemente, ele não estava sob efeito de drogas. Disseram que não havia 'sedas ou cachimbos' com o acusado.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.
(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Marlon Eduardo dos Santos Carvalho, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática delitiva. Disse que era usuário de droga e, naquele dia, havia adquirido 15 porções de 'crack' para seu consumo. Afirmou que estava no ponto de ônibus porque iria pegar o coletivo. Informou que as 38 porções foram apresentadas pelos policiais. Esclareceu que pagou cinco reais por cada porção de 'crack' e que, na época, 'pegava 15 porções para usar semanalmente'. Mencionou que foi a segunda vez em que foi confundido com traficante, sendo absolvido nas outras ocasiões.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas. O acusado negou o delito.

Todavia, os policiais o viram em local de tráfico, com 38 porções de drogas, e dinheiro (R\$ 40,00) cuja procedência não foi delineada.

Aliás, na fase policial, o acusado assim se manifestou (fls. 08): "(...) Disse que está passando por dificuldades e que recentemente até pensou em praticar roubos, porém como não compactua tirar dos outros o que foi conquistado com suor e muito trabalho, resolveu traficar. Disse que nesta data estava sentado em um ponto de ônibus perto da Praça Machado de Melo, já que no local há muitos usuários de entorpecentes, compradores em potencial. Disse que estava ali para vender a droga, quando viu a aproximação da viatura e por isso ficou nervoso e assustado. Disse que se levantou e tentou sair, mas que foi abordado (...)".

Ademais, o local era destinado ao tráfico.

Pelas mesmas razões, nos termos do art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06, não é possível a desclassificação para o delito de consumo pessoal.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (crack), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase,

para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, aplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

No caso concreto, além da presença dos requisitos legais, forçoso convir que a droga, ainda que de natureza perniciosa, era de quantidade diminuta (7,05g).

O montante de diminuição será de 1/3, visto que o acusado, efetivamente, realizava o comércio espúrio há alguns dias.

Por isso, a pena definitiva é de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

No aspecto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ARGUMENTOS INERENTES À CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS

ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENAS. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. ANÁLISE À LUZ DO CÓDIGO PENAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso em ação cabível, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica.
 2. Elementos inerentes à culpabilidade em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, não justificam a exasperação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável.
 3. Há constrangimento ilegal quando verificado que não foi apontado nenhum elemento concreto dos autos que efetivamente evidenciasse a acentuada danosidade decorrente do tráfico de drogas especificamente praticado pelo paciente, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime.
 4. A natureza e a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente autorizam a exasperação da pena-base, a teor do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
 5. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.
 6. Não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi aplicada a fração de 1/3 de diminuição de pena, visto que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a aplicação da minorante nesse patamar, salientando, para tanto, a diversidade de drogas apreendidas em poder do paciente (cocaína e maconha).
 7. Não se trata de bis in idem a consideração da quantidade e/ou natureza da droga apreendida na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, e na terceira etapa, para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, visto que se trata, na verdade, de um elemento sopesado em momentos distintos da dosimetria e com finalidades diferentes.
 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, tem-se que a invocação deste dispositivo não serve para justificar a fixação do regime mais gravoso, haja vista que, para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, deve o magistrado avaliar o caso concreto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal.
 9. No caso, a Corte estadual entendeu devida a fixação do regime inicial semiaberto com base justamente nas diretrizes traçadas pelo artigo 33 do Código Penal, razão pela qual não há nenhum ajuste a ser feito no modo inicial de cumprimento de pena.
 10. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, apenas para reduzir em parte a pena-base do paciente, tornando a sua reprimenda definitiva em 4 anos e 1 mês de reclusão, e pagamento de 394 dias-multa.
- (STJ, 6ª Turma, HC 229694 / MG, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 17/12/2013)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial semiaberto.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Contudo, a pena não ultrapassou os quatro anos, o que permite a incidência do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

As penas restritivas não podem ser lançadas, pela restrição contida no art. 44, III do Digesto Material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, desta maneira, CONDENO o acusado Marlon Eduardo dos Santos Carvalho, qualificado nos autos, a

cumprir a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu à parte do feito em liberdade, e nesta condição deve permanecer, pela ausência dos pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar, especialmente a contemporaneidade.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA